

1500988-61.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira
Comarca: Piracicaba
Foro: Foro de Piracicaba
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 31/01/2022

... específicos.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. COGNIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO EM PATAMARES DIFERENCIADOS NOS DOIS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 05/07, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19)3433-4177, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500988-61.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2171435/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9, 18695590 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9, 73/21/592 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9, 2171435 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS MACIEL MOREIRA e outro

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 31 dias do mês de janeiro de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Paulo Kishi e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a).Daniela Batalha Trettel. Apresentados o(a)(s) acusado(a)(s) MARCOS MACIEL MOREIRA E FELIPE ALBIGESI NOGUEIRA, e as testemunhas arroladas pela defesa: Sandra Aparecida Albigesi Nogueira, Anezia Teixeira Albigesi, Celso Lino de Oliveira. Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com seu(sua)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao(a)(s) acusado(a)(s) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal.

INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) (Sandra, Anezia e Celso) pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado(a)(s) o(a)(s) réu(ré)(s) (Marcos e Felipe).

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

“Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM. Juíza,

MARCOS MACIEL MOREIRA e FELIPE ALBIGESI NOGUEIRA, qualificados nos autos, estão sendo processados como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 combinado com o artigo 29, do Código Penal porque, no dia 24 de junho de 2021, por volta de 12h00min., na rua Pedro Ferraz Pacheco, nº 50, Piracicamirim, nesta cidade e comarca, guardavam e/ou mantinham em depósito 90 porções de crack e 226 porções de cocaína, para mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, substância entorpecente que causa dependência sem autorização ou em desacordo com a lei.

Autoria e materialidade restaram comprovadas nos autos.

Com efeito, o policial civil Marcelo Teixeira Mendes Lino narrou “recebeu informações dando conta que um indivíduo já conhecido nos meios policiais, identificado como sendo FELIPE ALBIGESI NOGUEIRA, vulgo “Figura”, o qual estaria responsável por um ponto de venda na Rua Pedro Ferraz Pacheco, naquele exato momento fracionava drogas em sua residência, localizada na mencionada via. As informações aportavam que FELIPE estaria contando com auxílio de um indivíduo também conhecido nos meios policiais, pelo vulgo “Mortadela”, identificado como sendo MARCOS MACIEL MOREIRA, o qual seria usuário de crack e receberia porções em troca. Ao chegar na residência e chamar por FELIPE, o depoente observou como MARCOS saiu no corredor e ao observar que tratava-se da equipe policial, gritou para FELIPE “moiou moiou joga fora” e então correu para o inteiro da residência. Diante das circunstâncias, o depoente adentrou no imóvel e logrou abordar MARCOS no último quarto da residência e FELIPE em um banheiro do mesmo cômodo, desfazendo das drogas no vaso sanitário. Após dominar e algemar ambos com apoio do policial LEONARDO, o depoente localizou em cima da cômoda do quarto um prato e uma faca com resquícios de crack, saquinhos utilizados para embalo, diversas pedras de crack já embaladas e prontas para venda – sendo algumas delas caídas ao solo, outras em cima da cômoda e mais algumas boiando dentro do vaso sanitário, totalizando 89 porções da droga. Questionado sobre mais drogas, FELIPE esclareceu que teria dado descarga em porções de crack já embaladas, bem como uma pedra bruta que ainda fracionava, as quais não foram possíveis recuperar. Realizadas buscas com o cão de faro EAGLE, este localizou uma sacola dentro do forro da cama box, contendo 228 porções de cocaína. Questionados, ambos confirmaram que FELIPE estava fracionando as porções de crack as quais, assim como as de cocaína, seriam comercializadas na rua de sua residência e que MARCOS estaria o auxiliando, bem como vigiando a porta, para em troca receber porções para uso, por ser viciado em ambas as drogas.” (fls. 02).

Em juízo ratificou integralmente o depoimento prestado na fase policial. Os réus confirmaram que estavam fracionando droga no local e destinava-se a venda. Marcos disse que era usuário e estava ajudando Felipe para ganhar algumas porções em troca. Já conhecia os réus, pois são reincidentes.

O policial civil Leonardo Cavalcanti asseverou “nesta data dirigiu-se até o local dos fatos para averiguar denúncia de que dois indivíduos conhecidos pelos vulgos “Figura” e “Mortadela”, identificados como sendo, respectivamente, FELIPE ALBIGESI NOGUEIRA e MARCOS MACIEL MOREIRA estariam fracionando entorpecentes no imóvel de “Figura”. Que ao chegar no local, o policial Marcelo chamou por FELIPE, sendo que então MARCOS saiu do último cômodo do imóvel e ao perceber que tratava-se da equipe policial, correu para o interior da residência gritando “moiou moiou, joga fora”. Que diante das circunstâncias, depoente e o policial Marcelo adentraram no imóvel e surpreenderam MARCOS na porta do quarto e FELIPE no banheiro existente no mesmo cômodo, se desfazendo de parte da droga no vaso sanitário. Que após dominarem e

algemarem ambos, localizaram 89 porções de crack prontas para vendas, sendo parte delas em uma cômoda do quarto, parte jogada ao solo e algumas delas boiando no vaso sanitário. Que na mesma cômoda localizaram um prato e uma faca com resquícios de crack e saquinhos idênticos aos utilizados para embalo daquela droga. Que com apoio do cão de faro EAGLE, desta especializada, lograram ainda localizar uma sacola contendo 228 porções de cocaína no interior da cama box, por um buraco no forro. Questionados, ambos confirmaram que FELIPE estava fracionando as porções de crack as quais, assim como as de cocaína, seriam comercializadas na rua de sua residência e que MARCOS estaria o auxiliando, bem como vigiando a porta, para em troca receber porções para uso, por ser viciado em ambas as drogas." (fls. 03).

Em juízo ratificou integralmente o depoimento prestado na fase policial. Fizeram diligência apenas na residência de Felipe. Não entraram na casa da mãe e da avó do réu Felipe. Não conhecia os réus antes dos fatos. Parte da diligência foi presenciada pela mãe do réu.

O policial Celso Lino disse em juízo que não participou das prisões dos réus. Os réus são conhecidos pela prática de delitos e são conhecidos nos meios policiais. Eles são conhecidos e moravam no bairro Maracanã, inclusive são muito amigos. Anésia disse que é avó do réu Felipe. Disse que viu um homem pulando o portão. Viu que tinha revólver na cintura e que era policial. Viu três policiais chegarem ao local. Viu o policial entrando correndo no local. Eles fizeram buscas num quartinho e a mãe do Felipe "foi junto".

Sandra disse que é mãe do réu Felipe. Soube que policiais pularam o portão da casa, quando estava sentada no quintal. Alega que o policial Marcelo "bateu nos meninos e levou uma mochila para sua casa". Felipe estava no quintal quando o policial pulou o portão. Estava na sua casa quando os policiais chegaram. Perguntou ao policial se apreendeu muita droga e ele respondeu positivamente.

Na fase policial, o réu MARCOS alegou "FELIPE pegou 7 pedras de crack de um moleque que lhe devia dinheiro e o interrogando pediu para usarem juntos. FELIPE convidou-o para entrar em sua casa e passaram a consumir drogas juntos. Policiais pularam o portão da casa e acusaram-nos de estarem picando droga para venda, o que não procede, pois não apreenderam dinheiro, em drogas em sua posse. Faz tratamento no Cedec, pois é soropositivo" (fls. 04).

Em juízo, o réu Marcos alegou que "é viciado há mais de 30 anos". Atualmente usa "crack". Já foi processado por furto e tráfico. Foi condenado em ambos. No dia dos fatos havia recebido dinheiro e comprou "5 papéis de crack". Avistou Felipe e ele convidou-o para entrar e consumir no quartinho dos fundos da casa dele". Foi ao local para consumir com Felipe. Não havia nenhuma droga no quartinho mencionado.

O réu FELIPE alegou "estava fumando crack no fundo de sua casa, na companhia de MARCOS, tendo policiais pulado o portão e disseram que ambos estavam picando droga para vender, o que não procede, já que é usuário de drogas" (fls. 05).

Em juízo, o réu Felipe disse que já foi condenado por tráfico de drogas. No dia dos fatos estava fumando crack com Marcos no quartinho dos fundos, quando foram abordados pelo policial Marcelo. Alega que Marcelo lhe disse "que jogaria um monte de droga nos réus". Foram agredidos pelo policial Marcelo que veio com um cachorro e uma mochila. Pratica furtos e os policiais não conseguiram recuperar uns televisores. Eles querem "arrumar para si". Já pagou pelo tráfico praticado. É usuário de drogas e pratica furtos para sustentar o vício. Nada tem contra os policiais.

As oitivas dos policiais colhidas em juízo estão em consonância com todo o apurado e demonstram de forma inequívoca a responsabilidade criminal dos réus.

Ao contrário, as palavras das informantes não merecem credibilidade, pois tratam-se da avó e mãe do réu Felipe, pessoas absolutamente suspeitas que têm interesse no desfecho do feito.

As alegações dos réus também estão isoladas e não merecem credibilidade.

Comprovou-se durante a instrução que os policiais receberam informações de que o réu FELIPE era responsável por receber e distribuir o entorpecente e que o corréu MARCOS o auxiliava na preparação do entorpecente. Assim, dirigiram-se ao local, onde avistaram o réu MARCOS, que, ao perceber a aproximação, gritou "moio, moio" e correu para o interior da residência. Diante da fundada suspeita, adentraram no

imóvel e flagraram o momento em que o réu FELIPE tentava se desfazer de parte do entorpecente. Em diligências, os policiais localizaram o restante da droga. Instados, informalmente, eles confessaram o crime. Assim, não restam dúvidas de que os réus foram autores do delito imputado na inicial. Outrossim, eles foram presos na residência com significativa quantidade de drogas.

Mister ressaltar que a palavra dos policiais é de grande relevância, não existem indícios nos autos de que quisessem prejudicar os réus e está em consonância com as demais provas obtidas. Nesse sentido:

“APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Valor do depoimento testemunhal de servidores policiais que, ratificados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Inexistência de contradições ou elementos de convicção que possam retirar-lhe a credibilidade. Dosimetria da pena mantida. Regime inicial fechado adequadamente imposto. Análise da detração que compete ao Juízo das Execuções Criminais. RECURSO DESPROVIDO” (Apelação nº 3005429- 53.2013.8.26.0320, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Camargo Aranha Filho, j .05/05/2016).

Ademais, consigna-se que a quantidade de entorpecente encontrada no local é incompatível com àquela trazida por usuários de drogas, o que confirma que o entorpecente destinava-se à mercancia ilícita.

Por outro lado, não é crível que os policiais trouxessem consigo relevante quantidade de droga apenas para incriminarem os réus injustamente, até mesmo porque não restou demonstrado qualquer motivo para agirem dessa forma. Ademais, caso quisessem, bastaria a quantidade “trazida pelos réus para consumo”.

Assim, indubitável que as versões apresentadas pelos réus são fantasiosas e não condizem com a verdade, tanto que restaram isoladas nos autos.

Destarte, diante do exposto, imperiosa a condenação dos réus pelo delito do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

DA DOSIMETRIA DA PENA

De acordo com o critério trifásico, na primeira fase, observadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, pois os réus ostentam Maus antecedentes.

Na segunda fase, a circunstância agravante da reincidência deve ser reconhecida a ambos (processo nº 3001175-32.2013.8.26.0451 – FELIPE e processo nº 0002512-68.2017.8.26.0451 – MARCOS). Ausentes circunstâncias atenuantes.

Os réus não fazem jus ao benefício do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, pois ostentam Maus antecedentes e são reincidentes específicos.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. COGNIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.

CULPABILIDADE. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO EM PATAMARES DIFERENCIADOS NOS DOIS CRIMES. PROPORCIONALIDADE. OBSERVAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, ORDEM DENEGADA. 1. O habeas corpus, como é cediço, não é meio próprio para pretensão absolutória, porque trata-se de intento que demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes do writ. Hipótese em que as instâncias de origem concluíram, com arrimo nas provas e fatos constantes dos autos, que tanto o delito de tráfico quanto de associação restaram plenamente caracterizados.

Reportando-se a diversos elementos de convicção, a sentença considerou a associação estável do paciente para a prática do crime de tráfico de drogas. Para se chegar a conclusão diversa, atendendo-se à pretensão de absolvição, seria necessário proceder à análise do conjunto fático-probatório amealhado ao feito, o que não se admite em sede de habeas corpus, via angusta por excelência. 2. A dosimetria é uma

operação lógica, formalmente estruturada, de acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. 3. Na espécie, não existe ilegalidade no tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, sob o vetor negativo da culpabilidade, porquanto a "especial perniciosa e vilaneza da organização criminosa integrada pelo acusado, Comando Vermelho" revela fundamentação suficiente à exasperação na primeira fase de fixação da reprimenda. 4. O quantum utilizado para aumento da reincidência, na segunda fase dosimétrica observou proporcionalidade, não sendo utilizado critério matemático único para ambos os crimes, eis que houve aumento de 1 ano quanto ao delito de tráfico de drogas e de 6 meses para o de associação para o tráfico. 5. Tratando-se de réu reincidente, inviável a concessão da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, que dispõe que "(...) as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços (...) desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa". Além disso, a condenação pelo cometimento do crime de associação para o tráfico também afasta a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado. 6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, ordem denegada" (HC 438.025/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, STJ - Sexta Turma, data do julgamento: 07/08/2018, data da publicação: 14/08/2018).

Ademais, o modus operandi demonstra que eles agiam com unidade de desígnios e organização entre si, inclusive divisão de tarefas, o que impede o reconhecimento do privilégio.

O regime inicial de cumprimento de pena mais adequado é o fechado, compatível com o montante da pena e reincidência.

Incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e suspensão da pena, pois ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

A prisão deverá ser mantida, tendo em vista que os réus são reincidentes. Portanto, deverá ser indeferido apelo em liberdade para garantia da ordem pública.

DO PEDIDO

Ante o exposto, o Ministério Público requer seja julgada procedente a presente ação, condenando-se os réus nos sobreditos termos.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s), manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM. Juíza, Marcos Maciel Moreira e Felipe Albigesi Nogueira foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c. c/ artigo 29, do Código Penal. Segundo a denúncia (fls. 135-137), no dia 24 de junho de 2021, por volta de 12h, na rua Pedro Ferraz Pacheco, nº 50, Piracicamirim, nesta cidade e comarca de Piracicaba/SP, Marcos e Felipe, supostamente, preparavam, guardavam e/ou mantinham em depósito 90 porções de crack e 226 porções de cocaína, para mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiros pessoas, substância entorpecente que causa dependência sem autorização ou em desacordo com a lei.

Ainda de acordo com a inicial, policiais civis receberam informações dando conta que "um indivíduo, identificado como Felipe Albigesi Nogueira, vulgo "Figura", seria responsável por um ponto de venda na rua Pedro Ferraz Pacheco" e que "naquele exato momento fracionava drogas em sua residência, localizada na mencionada via". Outrossim, que "ele contava com auxílio de um indivíduo conhecido pelo vulgo "Mortadela", identificado como sendo Marcos Maciel Moreira, que seria usuário de crack e receberia porções em troca". Assim, dirigiram-se até a residência de Felipe, onde ao chamarem por ele, observaram que Marcos saiu no corredor e ao perceber a presença policial gritou "moiou, moiou, joga fora" e correu para interior da residência. Diante da fundada suspeita, os policiais adentraram ao imóvel e surpreenderam Felipe, no banheiro, quando dispensava parte da droga no vaso sanitário e localizaram Marcos no último quarto do imóvel. Na cômoda do quarto foram localizadas uma faca com resquícios de "crack", saquinhos para embalo da droga e 89 pedras de crack, já embaladas e prontas para venda, sendo que algumas estavam caídas no solo e outras já no interior do vaso sanitário. Instado se havia

mais droga no local, Felipe alegou que as tinha jogado no vaso sanitário e dado descarga. Contudo, com auxílio do canil foram localizadas dentro de uma sacola escondida no forro da cama box 228 porções de cocaína. Questionados, informalmente, ambos alegaram que “Felipe estava fracionando as porções de crack e cocaína que seriam comercializadas na rua da residência e que Marcos estaria o auxiliando, bem como vigiando a porta, para em troca receber porções para uso, por ser viciado em ambas as drogas”.

Interrogado em solo policial, o réu Marcos contou que: “hoje, Felipe pegou 7 pedras de crack de um moleque que lhe devia dinheiro e pediu para usarem juntos. Felipe convidou-o para entrar em sua casa e passaram a consumir drogas juntos. Policiais pularam o portão da casa e acusaram-nos de estarem picando droga para venda, o que não procede, pois não apreenderam dinheiro, nem drogas em sua posse. Faz tratamento no Cedec, pois é soropositivo” (fls. 04).

Interrogado em solo policial, o réu Felipe disse que: “estava fumando crack no fundo de sua casa, na companhia de Marcos, tendo policiais pulado o portão e disseram que ambos estavam picando droga para vender, o que não procede, já que é usuário de drogas” (fls. 05).

Marcelo Teixeira Mendes Lino de Oliveira, policial civil, narrou que “recebeu informações dando conta que um indivíduo já conhecido nos meios policiais, identificado como sendo FELIPE ALBIGESI NOGUEIRA, vulgo “Figura”, o qual estaria responsável por um ponto de venda na Rua Pedro Ferraz Pacheco, naquele exato momento fracionava drogas em sua residência, localizada na mencionada via. As informações aportavam que FELIPE estaria contando com auxílio de um indivíduo também conhecido nos meios policiais, pelo vulgo “Mortadela”, identificado como sendo MARCOS MACIEL MOREIRA, o qual seria usuário de crack e receberia porções em troca. Ao chegar na residência e chamar por FELIPE, observou como MARCOS saiu no corredor e ao observar que se tratava da equipe policial, gritou para FELIPE “moioi joga fora” e então correu para o inteiro da residência. Diante das circunstâncias, o depoente adentrou no imóvel e logrou abordar MARCOS no último quarto da residência e FELIPE em um banheiro do mesmo cômodo, desfazendo das drogas no vaso sanitário. Após dominar e algemar ambos com apoio do policial LEONARDO, localizou em cima da cômoda do quarto um prato e uma faca com resquícios de crack, saquinhos utilizados para embalo, diversas pedras de crack já embaladas e prontas para venda – sendo algumas delas caídas ao solo, outras em cima da cômoda e mais algumas boiando dentro do vaso sanitário, totalizando 89 porções da droga.

Questionado sobre mais drogas, FELIPE esclareceu que teria dado descarga em porções de crack já embaladas, bem como uma pedra bruta que ainda fracionava, as quais não foram possíveis recuperar. Realizadas buscas com o cão de faro EAGLE, este localizou uma sacola dentro do forro da cama box, contendo 228 porções de cocaína. Questionados, ambos confirmaram que FELIPE estava fracionando as porções de crack as quais, assim como as de cocaína, seriam comercializadas na rua de sua residência e que MARCOS estaria o auxiliando, bem como vigiando a porta, para em troca receber porções para uso, por ser viciado em ambas as drogas” (fls. 02).

No mesmo sentido a versão apresentada pelo policial civil Leonardo Cavalcanti de Oliveira (fls. 03).

Às fls. 39-44, juntada certidão de objeto e pé de Marcos que indica os maus antecedentes (autos n.º 0018425-37.2010.8.26.0451 - pena cumprida ou julgada extinta em 06/05/2015) e a reincidência (autos n.º 0001841-18.2019.8.26.0502 - furto qualificado - trânsito em julgado para a Defesa em 22/11/2018; autos n.º 0002512-68.2017.8.26.0451 - tráfico de drogas - trânsito em julgado para a Defesa em 06/11/2018).

Às fls. 63-67, juntada certidão de objeto e pé de Felipe que indica a reincidência (autos n.º 3001175-32.2013.8.26.0451 - tráfico de drogas - trânsito em julgado para a Defesa em 16/10/2014 - condenado à pena de seis anos, nove meses e vinte dias). Requerido pela defesa a juntada do vídeo mencionado pelo policial Marcelo Lino que comprovaria a suposta justa causa para ingresso na residência. O pedido foi indeferido.

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade do delito se comprova pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10,

laudo pericial de constatação de fls. 14-18, fotografias de fls. 23-25 e laudo de exame definitivo de fls. 123-125 e laudo dos objetos apreendidos de fls. 130-132. Com relação à autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

a) Ouvido, inicialmente, o policial civil Leonardo Cavalcanti de Oliveira. O policial Marcelo teria recebido uma denúncia dando conta de que os dois indivíduos estavam fracionando drogas na residência. Chegando no local, Marcelo chamou e Marcos estava no corredor, olhando entre o quarto e o corredor. Marcos saiu gritando “Molhou, molhou, joga fora”. O portão estava encostado. O portão era de ferro, tipo vergalhão, através do qual é possível ver. O portão dá acesso a um corredor. A casa fica lateralmente ao corredor. A casa do primeiro acesso estava a mãe na cozinha, uma lavanderia, e o cômodo em que estavam era o último. Marcelo chamou e Marcos colocou a cabeça no corredor, quando viu que se era a polícia e gritou. Nesse momento, Marcelo notou que o portão poderia ser aberto somente puxando o trinco. Ele abriu e correram até o fundo da residência. Foram até o quarto do fundo. Havia diversas portas. Esse dormitório em que Marcos e Felipe estavam, era uma última porta. Não era necessário ingressar na casa para chegar nesse cômodo. Entraram no quarto. O depoente abordou Marcos e Marcelo abordou Felipe, que estaria jogando entorpecentes no vaso sanitário. No vaso foi localizado crack, mas não se recorda quantas porções. O perito disse que a descarga levou uma pedra bruta. Marcos estava no quarto, onde o depoente localizou 89 porções fracionadas, algumas no chão e outras sobre uma cômoda, e uma faca usada para fracionamento. Havia um prato no chão, onde estavam fracionando, não se recorda se as drogas dentro desse prato já estavam embaladas ou só fracionadas. Também havia saquinhos de jujuba, que usam para embalar. Não sabe se essas porções consideram as encontradas no vaso sanitário ou não. Posteriormente, o cão de faro localizou 228 porções de cocaína. Entrevistados separadamente, ambos confirmaram que estavam fracionando drogas. Marcos estaria somente ajudando e seria pago em entorpecentes. Não ingressaram na casa da mãe e da avó. Ambas ficaram tristes com a situação, pois Felipe tinha saído a pouco tempo da cadeia. Não conhecia os réus, mas o policial Marcelo já os conhecia. Respondeu, então, às perguntas da defesa. [O quarto era um cômodo separado?] Sim, era quase uma casa separada, mas não tinha cozinha. [Foram autorizados a ingressar na casa?] Por conta da informação privilegiada que Marcelo detinha, haveria flagrante e, diante da fala de Marcos, entenderam que cabia a entrada na casa por haver flagrante. [A descarga estava funcionando?] Não sabe, não entrou no banheiro. [Havia petrechos para uso de drogas?] Sim. Havia cachimbo para uso de crack, e Marcos confirmou que era dele. [Quem acompanhou as diligências? Os senhores permitiram que os familiares de Felipe acompanhassem as buscas?] A mãe acompanhou parte, mas quis voltar para cuidar da comida que estava fazendo para a mãe. Foi chamada para ver a droga localizada. Os réus não acompanharam a diligência. Havia duas equipes no local, a parte do cão de faro foi acompanhada pelos réus. [Felipe foi abordado anteriormente por conta do furto de uma TV noticiado na mídia local?] Marcelo comentou do caso, e também circulou a informação sobre o furto e que o autor seria Felipe nos grupos dos policiais.

b) Em seguida, ouvido Marcelo Teixeira Mendes Lino de Oliveira, policial civil. Relatou que chegou uma informação muito precisa de que os réus estavam fracionando drogas no último quarto da residência, que é um quarto isolado e independente. Marcos estaria ajudando. Ao chamar no portão, Marcos começou a gritar “Moio, moio, joga”. Entrou, deu de cara com Felipe jogando as drogas no vaso sanitário e jogando água com um balde. O portão era de ferro fino, que permitia ver do outro lado, e baixo (1,40/1,50m). Do portão, não dava para ver da rua o quarto. É um corredor bem fundo, com portas do lado direito. Não é um imóvel só, é uma casa que foi fracionada. O quarto do réu só tem um acesso ao banheiro, não ao restante da casa. Quando Marcos gritou, empurrou o portão e correu para o quarto dos fundos. Deparou-se com o réu Felipe jogando com uma mão a droga, empurrando, no vaso, e com um balde jogando água. A descarga estava quebrada. Na descarga, algumas porções boiaram. Em uma cômoda, havia mais droga. Total de 89 porções de crack. O réu Felipe disse que jogou a pedra bruta no vaso sanitário. O cão de faro localizou embaixo da cama box, dentro do forro, uma sacola com cocaína (228 porções). Ambos

confessaram o fracionamento. Felipe venderia a droga na rua, que é conhecida pelo tráfico, e Marcos estaria ajudando para receber entorpecentes em pagamento. Tinham vários parentes, mas não acompanharam a diligência, sequer foram ao cômodo, deram “graças a Deus” pela prisão, um deles agradeceu. Apenas foram à viatura para saber o motivo da prisão. A mãe e a avó somente viram a saída de Felipe do quarto, não entraram no quarto. Marcelo mostrou o vídeo para a mãe que mostraria o achado da droga. Ela não demonstrou reação, disse que já sabia que isso ia acontecer uma hora. Perguntado sobre a situação do portão de entrada, disse que estava encostado e sem tranca. Não ingressaram na casa dos parentes/demais cômodos. Não se recorda se os réus acompanharam a busca do cão de faro, acha que Felipe sim. Já conhecia ambos os réus. prendeu Felipe há 4 anos, quando ele era foragido. Marcos é conhecido nos meios policiais por furtos e está sempre em biqueiras. Não localizaram petrecho para uso de drogas. [De onde veio essa informação sobre o fracionamento de drogas, como chegou?] A informação veio da família, inclusive com imagem. Não pode juntar a imagem no processo porque exporia quem a fez. [Foram autorizados a ingressar na casa?] Como tinha certeza absoluta do flagrante, não precisava da autorização. [Felipe foi abordado anteriormente por conta do furto de uma TV noticiado na mídia local?] Sabe que uma equipe da polícia civil o pegou em filmagens. [Perguntou sobre a TV durante a abordagem?] Havia uma TV no quarto de Felipe e perguntou a ele se era roubada, mas não apreendeu porque não batia com a descrição de aparelhos furtados/roubados em boletins de ocorrência.

c) Na sequência, ouvido o policial civil Celso Lino de Oliveira. Sobre os fatos, disse que não participou da prisão. A prisão foi realizada pelo filho e o policial Leonardo, da DISE. Conhece os réus, são conhecidos dos meios policiais por furto e tráfico. Trabalhou na área em que moram, no bairro Maracanã, em especial o Felipe. Os dois presos são amigos. Na época da prisão, teve contato com os réus, teve furto. Eles são “clínicos gerais”, furtam e traficam. Réus foram ouvidos e confessaram o furto de uma televisão na delegacia. O réu Felipe foi quem confessou. Disse que não comentou com o filho que esses réus estavam novamente na rua, mas é de conhecimento da polícia.

d) Na sequência, ouvida a testemunha Anezia Teixeira Albigesi. É avó do réu Felipe. Perguntada sobre o dia em que o neto foi preso, disse que se levantou de manhã, abriu a porta da cozinha e viu um homem pulando o portão. Ia gritar, mas viu o revólver na cintura desse homem e percebeu que era polícia. Aí ficou quieta. Quando ia falar para não pular o portão, viu o revólver e ficou quieta. Todos pularam o portão, gritavam “polícia”, colocaram Felipe para fora e o outro, ficou um pouco lá dentro do quartinho, saiu e voltou com uma mochila e um cachorro. Sabe que o Felipe é usuário, mas nunca viu “essas coisas” na sua casa. Felipe estava no quartinho com um moço. Não sabe o que estavam fazendo no quartinho. Entraram na sua casa, pelo menos, 3 policiais, que foi o que viu. [Autorizaram a entrada da polícia na casa?] Não, eles entraram correndo e mandaram fechar a porta. [As drogas apreendidas foram mostradas para a senhora?] Não. A filha Sandra foi ver o que estava acontecendo, mas voltou rápido. [Sabe do envolvimento de Felipe no tráfico?] Não, sabe que ele usa drogas.

d) Ouvida, em seguida, Sandra Aparecida Albiesi Nogueira. É mãe de Felipe. No dia dos fatos, o policial pulou o portão. Felipe estava com um colega dele, Marcos, mas não estava traficando. Os policiais até quebraram o portão ao pular. Falaram que, se não achassem algo, iam pegar o cachorro. Marcelo saiu sem nada, mas voltou com uma mochila nas costas. O policial Marcelo também bateu nos meninos. Mandou que fechassem a porta. O policial pediu desculpas para ela quando estavam na viatura. Felipe infelizmente é usuário de crack. Já perdeu um filho para as drogas. Odeia esse tipo de coisa. Os policiais chegaram na sua casa por volta de 10h. Felipe e Marcos estavam no quintal da casa, sentados. Sandra estava sentada, dentro de casa, arrumando o almoço. Os policiais mandaram fechar a porta, e achou estranho. O pai de Marcelo sempre entrou na sua casa com mandado, agora Marcelo invadiu a sua casa. Não entendeu essa atitude. Não acompanhou as buscas porque mandaram fechar a porta, mas espiaram pelo vitrô. Viu que Felipe, antes, estava com uma pedrinha no quintal. Moravam na casa o irmão com deficiência, ela, sua mãe e Felipe. Ninguém denunciou Felipe para a polícia, nem tem telefone celular, só telefone fixo. Os policiais não

pediram autorização para entrar em sua casa. Encheu de viaturas, parecia que iam prender alguém perigoso na Cracolândia. Não lhe mostraram as drogas, mas o policial Marcelo disse que era bastante crack e cocaína. Estranhou que o policial voltou com uma mochila. O filho é viciado em crack e sabe que já fumou maconha, mas não usa cocaína.

e) Iniciados os interrogatórios, o réu Marcos Maciel Moreira. Tinha comprado crack e estava descendo a rua para ir usar a droga no mato. Passou, viu Felipe e ele pediu para fumar junto. Felipe chamou para fumarem no quartinho. Estava ali, viu os policiais pulando o portão e realmente avisou da invasão. Marcelo chegou perguntando para Felipe de uma televisão, e não entendeu porque não tinha nenhuma TV no quartinho. Marcelo revirou a casa, achou as drogas, o outro investigador achou o cachimbo. Tinha acabado de chegar ali, só ouviu a abordagem dentro do quartinho, não viu as drogas que Marcelo falou no seu depoimento. Durante a diligência, mandaram ele ficar sentado sobre suas mãos no lado de fora. Não apresentaram drogas para ele, para a família ou para a polícia. Não viu essa droga. Reviraram tudo, viu da lavanderia. Felipe falou que tinha algumas baganas de maconha na cômoda. Sobre a TV, não tem nada a ver com isso, foi coisa de Felipe e Rogério. Estava trabalhando, não estava mais furtando. Não mostraram droga para ele, só o cachimbo e as baganas de maconha. Depois que reviraram tudo e não acharam nada, saíram e voltaram com um cachorro do canil e entraram com diversos investigadores. Tinha um monte de viaturas. Marcelo falou que ia quebrar o vaso. Mas a privada estava sem descarga. É usuário de crack. Fica livre das drogas, mas tem recaídas depois de 1 ou 2 meses.

f) Por fim, foi interrogado o réu Felipe Albighesi Nogueira. No dia dos fatos, entre 10h30 e 12, viu Marcos descendo a rua da sua casa. Perguntou aonde ele ia, Marco disse que ia fumar crack no mato. Chamou Marcos para entrar e fumaram as pedras juntos. Quando viu, Marcelo já estava apontando a arma para ele. Estavam dentro do quartinho do fundo. É só um cômodo. Marcelo falou que estavam “picando” droga, disse que não, e disse que poderia procurar. Disse que só tinha baganas de maconhas. Marcelo abriu as gavetas, achou as pontas de cigarro de maconha. Marcelo começou a perguntar da televisão, ele respondeu que já tinha conversado a esse respeito com o pai dele (conhecido como “Boiadeiro”). Marcelo colocou os dois sentados no rancho que fica na frente do quartinho, deu chutes, voltou com uma mochila e um cachorro. A mãe saiu e disse que queria acompanhar, não deixaram. Eram muitos policiais, tinha duas blazers e mais carros à paisana. Ficou poucos minutos dentro do quartinho e logo saiu. Ninguém dizia qual a acusação pela qual estava preso, só soube no CDP. Assume que usa crack e furta para sustentar o vício. Acha que ficaram com raiva dele por conta disso e devem ter lhe imputado o tráfico. Mora mesmo perto de ponto de venda, é a casa da família, mas não trafica. Realmente usa droga junto com Marcos, andam na comunidade da região desde jovem, mas não trafica. Fuma crack e maconha. Não consegue ficar sem, é viciado. Marcelo já o prendeu outra vez, quando não voltou de saída temporária. Não tem nada contra os policiais. O policial Celso já foi diversas vezes em sua casa, mas nunca invadiu como fez o Marcelo (filho do Celso, conhecido como “Boiadeiro”).

- DA NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA A PARTIR DA VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO

Preliminarmente, deve-se reconhecer a ilicitude de toda prova produzida a partir do ingresso dos policiais no domicílio do acusado Felipe, eis que a entrada no local se deu com violação ao princípio constitucional que assegura a inviolabilidade do domicílio. Isso porque não há prova nos autos de que houve consentimento de pessoa que ali residia para ingresso no local.

Ressalte-se que os policiais, em seus depoimentos, relataram que a polícia civil já acompanhava a movimentação dos réus. Investigações teriam sido realizadas. Assim sendo, não há dúvidas de que transcorreu tempo hábil para requisição de mandado de busca e apreensão. Os juízes e promotores atuantes na Comarca, assim como os seus serventuários, são de extrema confiança e responsabilidade, sendo certo que, trazidas ao Poder Judiciário as provas mencionadas pelo policial, a ordem seria concedida e o sigilo a seu respeito seria preservado. Todavia, ao escolherem atuar à margem da legalidade e invadir a casa de uma pessoa fora das hipóteses constitucionalmente previstas, as forças policiais não só desrespeitaram a

legislação e os poderes atribuídos exclusivamente aos membros do Poder Judiciário, como também macularam toda a investigação e o processo. Trata-se de fato lastimável, que ataca frontalmente a democracia e os poderes constitucionalmente instituídos.

Ademais, há relato nos autos de que o policial responsável pela prisão e o seu genitor, também policial, estavam no encalço do réu Felipe em razão do furto de uma televisão, havendo fundadas razões para que se desconfie até mesmo da veracidade de seus depoimentos quanto à existência de uma denúncia anônima de alguém da família de Felipe. Requerida a juntada nos autos de informações sobre a suposta denúncia, o pleito defensivo foi negado. Fosse verdade que alguém da família, residente na casa, concordava com a incursão no imóvel, bastava à polícia e a acusação informarem tais fatos nos autos – o que não fizeram. De qualquer maneira, caberia à acusação comprovar a justa causa do ingresso no domicílio sem autorização de moradores ou ordem judicial, o que não o fez. Conforme assentada jurisprudência, denúncia anônima não é fundada razão.

Considerada a essencialidade da proteção ao domicílio para a garantia da tranquilidade e bem-estar dos indivíduos, as hipóteses em que agentes do Estado ou mesmo terceiros podem ingressar em habitação alheia sem autorização do morador são limitadas pela Carta Magna às seguintes: a) flagrante delito; b) desastre; c) para prestar socorro; d) por determinação judicial, durante o dia.

Para que não se esvazie o comando contido no artigo 5º, inciso XI, da Carta da República, há de se entender que o flagrante que justifica a invasão de domicílio é apenas aquele que ocorre em situação de emergência.

Roberto Delmanto Junior, em sua obra “As modalidades de prisão provisória e seu prazo de duração”, diferencia com perfeição as situações em que se justifica a relativização da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, todas elas baseadas no conceito constitucional de emergência e não de flagrante delitivo de crime permanente, até porque o texto constitucional não se apropria deste conceito penal. Transcrevo: “Sem dúvida, a exceção constitucional à inviolabilidade domiciliar, inclusive em horário noturno e sem determinação judicial, nos casos de flagrante delito, que é disposta ao lado das hipóteses de desastre ou prestação de socorro (art. 5º, XI, 1ª parte) há que ser interpretada sistematicamente, restando patente a intenção do legislador em exigir a configuração de uma verdadeira emergência para que se admita a violação domiciliar, sem determinação judicial, seja ela noturna ou mesmo diurna. Seriam hipóteses, por exemplo, de flagrante de crimes como a extorsão mediante sequestro, em que há necessidade de prestar-se socorro à vítima, que corre perigo de vida etc., o que não se verifica em casos de crimes permanentes como a simples posse de entorpecente ou de armas ilegais. Não havendo esse caráter emergencial, de perigo iminente a um bem jurídico como a vida e a integridade física, a autoridade deverá, sim, obter determinação judicial para invadir o domicílio do suspeito (art. 5º, XI, 2ª parte, da Constituição da República), através da expedição de mandado judicial de busca e apreensão (arts. 240 a 250 do Código de Processo Penal) e não invadir a residência alheia a qualquer hora e sem autorização judicial (o que poderia configurar, inclusive, o crime do art. 150 do Código Penal, dependendo da análise dos incisos I e III de seu §3º, que também devem ser interpretados de acordo com a Magna Carta), sob o pretexto de estar diante de eventual crime permanente, em acusações absolutamente infundadas e, de fato, inexistentes. Por outro lado, justamente para evitar constrangimentos infundados, é que o art. 243 do nosso estatuto processual exige o preenchimento de uma série de pressupostos para a expedição de mandado de busca e apreensão. Poder-se-ia dizer que esse entendimento poderia obstaculizar muito a ação policial; todavia este é um preço pequeno que se paga por vivermos em um Estado liberal e democrático de direito, que sempre deve tomar todas as medidas para restringir, ao máximo, a possibilidade de arbítrios e desmandos das autoridades policiais, por mais bem-intencionadas que possam elas estar.” (Obra supracitada, Ed. Renovar, 2ª Edição, 2001, páginas 107/108).

Na hipótese, como não havia perigo iminente a terceiros e nem risco de a prova ser danificada, modificada ou destruída, não havia justificativa razoável para o ingresso forçado na residência do acusado, restando claro que a busca realizada

pelos policiais foi abusiva e ilegal, sendo inaceitável a prova produzida a partir deste ato.

Conforme consolidada jurisprudência dos tribunais superiores, é ônus do Estado comprovar que houve autorização dos moradores para ingresso no domicílio ou que havia justa causa para acesso à residência do acusado sem ordem judicial. Da mesma forma, devem comprovar os fatos que alegam na comprovação das fundadas razões. Tem-se, assim, que o ingresso na residência do réu Felipe deu-se em desconformidade com a garantia do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A esse propósito, deve-se frisar que, não obstante seja permitida a busca pessoal independentemente de mandado judicial (CPP, art. 244), a busca domiciliar somente poderá ser realizada quando o ingresso na residência seja legítimo, isto é, com "[...] o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial." (CF, art. 5º, XI). Com efeito, nos termos do art. 241 do Código de Processo Penal, "Quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado". Todavia, ainda que tal dispositivo pareça autorizar a busca domiciliar sem a prévia expedição do mandado de busca e apreensão, é certo que não foi ele recepcionado pela atual Constituição Federal, cujo art. 5º, XI, estipula que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial."

Sendo assim, é inquestionável que houve violação ao domicílio do acusado (CF, art. 5º, XI), de modo que os autos de exibição e apreensão e de entrega de fls. 07 e 08 são oriundos de uma ilicitude (CF, art. 5º, LVI c. c/ CPP, art. 157) e, por isso, são imprestáveis para a formação do convencimento judicial.

Da mesma forma, qualquer prova produzida em decorrência de tal apreensão, resta contaminada pela ilicitude, devendo ser desentranhado dos autos e não podendo ser considerado na formação da convicção do juízo (CPP, art. 157, caput).

Portanto, inexistindo provas contra os acusados, eis que a materialidade delitiva foi construída a partir da entrada ilegal no domicílio do acusado Felipe, o caso é de absolvição com fulcro no artigo 386, inciso V, CPP.

- DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

Caso se entenda pela licitude da atuação da guarda, de rigor a improcedência da pretensão acusatória. Isso porque, em audiência de instrução e julgamento, não foram produzidos elementos de prova que permitam concluir, além de qualquer dúvida razoável, pela responsabilidade penal dos réus (CPP, art. 386, V e VII c. c/ art. 155).

Observa-se que, no caso concreto, eventual sentença de condenação estaria embasada apenas nas declarações dos policiais, elementos de prova de reduzido valor, tendo em vista a parcialidade de suas declarações. Nesse contexto, a jurisprudência do TJ-SP e a doutrina são pacíficos em lhes reconhecer o valor probatório, desde que confirmados por outros elementos de prova. Isso porque as declarações dos agentes de segurança são tendentes a confirmar a sua própria atuação, motivo pelo qual se impõe cautela na sua apreciação (TJ-SP, 7ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0373088-52.2010.8.26.0000, Relator Sydnei de Oliveira Jr; TJSP - 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin - j. 03/02/11). Assim, seria necessário que fossem confirmadas por outros elementos de prova. E tal exigência não significa um demérito à atuação dos policiais; pelo contrário, reconhece-se a importante função que desempenham, mas se pugna que suas palavras sejam apreciadas com cautela, tendo em vista as suas condições e o histórico de violência institucional que caracteriza a polícia brasileira, como, aliás, reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Cosme Rosa Genoveva vs. Brasil.

Aliás, no caso concreto, há fatos que colocam em dúvida o depoimento do policial Marcelo, responsável pela busca e apreensão e líder na diligência. Conforme demonstrado nos autos, ele e o seu pai, também policial civil, estavam no encalço do acusado Felipe por conta do furto de uma televisão. Quando da invasão do domicílio, o policial Marcelo ameaçou o acusado Felipe, exigindo a entrega do

aparelho de televisão. Na impossibilidade, feito o flagrante de tráfico, a fim de garantir a sua prisão. Chama atenção no depoimento das testemunhas o fato de que o policial Marcelo entrou na casa, nada encontrou, e depois retornou com uma mochila. Não permitiu que ninguém acompanhasse a diligência e não mostrou as drogas supostamente encontradas.

Além disso, as testemunhas Sandra e Anezia, pessoas idôneas e simples, foram claras quanto ao fato de que não autorizaram o ingresso na sua casa, não tiveram autorização para acompanhar a diligência e não viram as drogas supostamente apreendidas. Além disso, viram o policial retornando com uma mochila.

Isso posto, conclui-se que os elementos de prova disponíveis nestes autos não são suficientes para superar o standard probatório da presunção de inocência, porquanto não permitem uma conclusão, além de qualquer dúvida razoável, sobre a responsabilidade penal dos acusados. De rigor, por isso, que se decrete sua absolvição, na forma do art. 386, VII, do CPP.

- ALEGAÇÕES RELATIVAS À DOSIMETRIA DA PENA

a) Pena-base

Na remota hipótese de condenação, de rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal: as consequências e a culpabilidade são normais para o caso, não justificando uma reprovação penal maior.

No mais, as condenações anteriores devem ser avaliadas na segunda fase de fixação de pena, sob pena de bis in idem.

b) Da segunda fase da dosimetria

Na segunda fase, há a reincidência dos réus permitindo o aumento da pena em 1/6. No mais, tendo em vista que, pelo relato dos policiais, os acusados confessaram a traficância, deve-se também computar a atenuante da confissão, compensando-a com a reincidência.

- REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, em atenção ao disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, diante da quantidade pena a ser aplicada e das circunstanciais judiciais, inexistindo fundamentação concreta a recomendar o regime mais gravoso (Súmulas 718 e 719 do STF; Súmula 440 do STJ), de rigor a aplicação de regime diverso do fechado.

Adicionalmente, para a fixação do regime inicial, não poderá ser observado o disposto no art. 1º, § 2º, da LCH, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade pelo STF, exercendo sua função típica de guardião da Constituição e, por isso, proferindo uma decisão de observância obrigatória por todo o Judiciário (CF, art. 102 c. c/ art. 927 do CPC).

- DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA COMO TEMPO DE PENA JÁ CUMPRIDO (DETRAÇÃO E ART. 387, § 2º, DO CPP)

Além disso, considerando que os réus responderam presos ao processo, impõe-se que o tempo de prisão provisória seja declarado como tempo de pena já cumprida, efetuando-se, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, a detração; é o que se extrai do referido dispositivo, assim como da Exposição de Motivos da Lei n. 12.736/2012 e da jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 652.915/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

- DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

Finalmente, deve ser assegurado aos acusados o direito de apelar em liberdade. De acordo com o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, ao proferir uma sentença de condenação, "O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". Ademais, a decisão pela manutenção da prisão preventiva deve ser concreta, cabendo ao julgador "[...] indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada" (CPP, art. 315, § 2º). Com efeito, uma vez encerrada a instrução, ainda que se entenda